

1500737-11.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... o acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista - SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500737-11.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500737-11.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS JUNIO SANTOS MARTINS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de DOUGLAS JUNIO SANTOS MARTINS e EMERSON PEREIRA DOS SANTOS, na qual lhes é imputada a prática de infração penal (art. 33, "caput", da Lei nº11.343/06, c.c. art. 14, "caput", da Lei 10.826/04, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do art. 69 do CP).

Narra-se na denúncia que no dia 5 de julho de 2021, por volta das 10h56, na Rua Um, altura do n. 100, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Nazaré Paulista-SP, EMERSON PEREIRA DOS SANTOS e DOUGLAS JUNIO SANTOS MARTINS, qualificados nos autos, agindo previamente ajustados e com identidade de desígnios com a adolescente Nathalie Rocha do Nascimento, traziam com eles, para fins de tráfico, 100 (cem) porções de cocaína, pesando aproximadamente 97,7g, 825 (oitocentos e vinte e cinco) porções de cocaína, pesando aproximadamente 874,4g, e 8 (oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 73,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de modo, tempo e local, possuíam 1 (um) revólver calibre 32, número HI15263, Taurus, de uso permitido e 6 (seis) cartuchos íntegros do mesmo calibre, sem autorização legal. Por fim, nas mesmas circunstâncias anteriores os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção da menor Nathalie Rocha do Nascimento, com ela praticando as infrações penais acima

descritas. (fls. 172/175).

A denúncia foi recebida em 04/02/2022.

Promovida a citação (fls. número), DOUGLAS JUNIO SANTOS MARTINS apresentou resposta à acusação (fls. 317).

Promovida a citação (fls. 446), EMERSON PEREIRA DOS SANTOS apresentou resposta à acusação (fls. 313/314).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do art. 33, "caput", da Lei nº11.343/06, c.c. art. 14, "caput", da Lei 10.826/04, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do art. 69, "caput" (concurso material), do Código Penal.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 3/8), pelo laudo de exame pericial (fls. 238/240), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. Constam dos autos, ainda, os seguintes elementos probatórios: auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de constatação preliminar (fls. 18/19), imagens de páginas de caderno contendo anotações de dívidas (fls. 45/46 e 53/54) e fotografias dos entorpecentes e ependorfs (fls. 47/51).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Romário Costa de Souza (policia militar) relatou que estavam em patrulhamento na região central da cidade, quando receberam denúncia por pessoa que não quis se identificar, passando dados de ocorrência no sentido de que haveria um indivíduo portando arma de fogo; que, de pronto, deslocaram-se ao local informado, quando na Rua 1 avistaram uma pessoa do sexo feminino carregando uma mochila; que ela, ao visualizar a viatura, tentou se evadir, e em revista na mochila localizaram drogas e dinheiro, sendo mais de R\$ 7.000,00 em dinheiro, cocaína e maconha; que, indagada, ela confessou que a droga era de seu namorado; que, de pronto, já sabiam de quem se tratava, por ser conhecido; que na residência ela disse que haveria um revólver pequeno; que solicitaram autorização para verificar o armamento, pois não poderiam deixar em posse de terceiros; que se deslocaram à residência e em uma cômoda de pronto já localizaram invólucros de droga e armamento municiado, salvo engano com seis munições intactadas; que, durante a revista, visualizou uma motocicleta em direção a esse local e de forma suspeita ao notar a presença policial tentou se evadir; que abordaram o indivíduo e com ele localizaram droga e dinheiro, salvo engano R\$ 500,00; que, indagado, ele confessou que teria dívida com o tráfico e teria que devolver tanto o dinheiro quanto a droga, que disse pertencer a Douglas; que ambos receberam voz de prisão; que já na delegacia Douglas compareceu quando em alto e bom tom gritava que toda a droga era dele e ela não tinha nada a ver com a história, mas foi elaborado BO de porte ilegal de drogas e arma; que a denúncia anônima relatou pessoa branca, de pessoa masculina, e em nenhum momento mencionou pessoa do sexo feminino; que o denunciante disse que achava que poderia ser caça ilegal; que todo o valor e droga estavam na mochila, só a arma não estava; que acredita que como a viatura estava na área, ela levaria essa droga de lá, provavelmente esconderia no mato; que já havia visto a adolescente, mas não se lembra se a abordou diretamente ou ela só estava próximo; que, depois disso, abordou-a algumas vezes depois; que conhece Douglas por denúncia e por sua família envolvida no meio criminal, inclusive seu irmão Jonathan; que ele assumiu o

tráfico no local logo após Jonathan ser preso; que não se recorda de tê-lo abordado antes, mas depois sim; que nunca teve discussão com Douglas; que não conhecia Emerson; que abordou primeiro e salvo engano chegaram depois o cabo Denis e outro policial; que entre a liberdade provisória e a prisão preventiva nunca mais o abordou, só o conduziu durante uma apreensão em flagrante de tráfico em que ele veio a defender os indivíduos que estavam sendo presos, e veio a responder por desacato e desobediência; que acompanhou a abordagem a Emerson, presenciou a revista pessoal, feita por Claudinei; que presenciou a localização de droga no bolso da calça; que a rua é sem saída, é um bairro em construção; que, de onde ele estava, ele foi surpreendido, por isso a moto se evadiu e o deixou; que ele desceu da moto e então foi abordado, aí a moto conseguiu se evadir, pois o motoqueiro ainda estava sobre a moto; que acredita que ele não viu a viatura, não tinha como ele ver, senão teria voltado; que a casa é na mesma rua da abordagem, chuta que a adolescente estava a cerca de trinta metros da casa, estava descendo da rua; que foram a pé à casa; que a adolescente estava tranquila, informou o nome do namorado, a arma, e apontou onde estaria a arma; que a arma configurou urgência e perigo e por isso não solicitaram policial feminina e por isso entraram na casa por segurança; que não conhecia a adolescente; que a adolescente informou que morava lá já há um tempo; que só os dois moravam lá; que ela informou que a família dela era de Atibaia; que Emerson saiu da moto antes de ver a viatura, e, ao ver, "travou". A testemunha Claudinei Gomes dos Santos (policial militar) relatou que estavam em patrulhamento quando foram informados por um indivíduo que não quis se identificar que haveria um indivíduo no sítio dos Pires, na primeira rua da vila, teria uma arma de fogo; que com essas informações foram ao bairro e então visualizaram a menor com uma mochila e quando ela percebeu a presença da viatura ela tentou voltar correndo, quando foi alcançada; que foi localizada com ela grande quantidade de droga e dinheiro; que ela disse que a droga seria do namorado Douglas; que ela disse que não haveria mais droga na casa, mas haveria arma; que por questões de segurança e procedimento diante da urgência da ocorrência solicitaram que ela acompanhasse a entrada na casa; que ela acompanhou; que localizaram a arma com seis munições intactas e próximo a esse revólver localizaram cerca de mil ependorfs vazios, utilizados para acondicionamento de cocaína; que quando terminavam a diligência, visualizaram a aproximação de uma motocicleta; que o garupa desceu e o que estava conduzindo na motocicleta continuou na moto; que, quando se aproximou, o motociclista fugiu e o garupa foi abordado, e com ele localizaram cerca quantidade de drogas e dinheiro; que ele disse que iria devolver parte da droga e quantia em dinheiro para Douglas; que quase no final da operação Douglas compareceu à delegacia espontaneamente e se declarou proprietário da droga, do dinheiro e da arma; que não conhecia a adolescente; que Douglas já conhecia, sabia dele, já tinha várias denúncias de moradores de que ele estaria na traficância na região do abacateiro e que inclusive ele teria assumido a gerência do tráfico após a prisão dele, Jonathan; que não se recorda se já o havia abordado, mas sabia quem ele era; que a adolescente deve ter falado há quanto tempo estava com ele, mas não se lembra, só lembra que disse que ela era de Atibaia e tinha se mudado para morar com ele; que o local dos fatos é uma rua sem saída de terra, difícil acesso, um bairro em construção, com casas quase todas sem terminar; que a rua dá acesso ao mato ao fundo; que foi ele que abordou e revistou Emerson; que há uma rua principal e para chegar nela é preciso pegar uma outra rua bem estreita; que acredita que ele não viu a viatura, porque as viaturas estavam estacionados em uma espécie de garagem da residência abordada; que do local ele desceu acredita que ele não viu; que viu a moto se aproximando porque estava mais próximo da rua; que, quando ele desceu da moto, foi abordá-lo, e o rapaz que estava na moto conseguiu escapar. O acusado Douglas Junio Santos Martins relatou que é verdade; que os policiais mentiram em alguns pontos; que estava envolvido com o tráfico porque até mesmo quando era menor ficou com uma dívida alta, de R\$ 10.000,00; que tentou fazer seu corre em cima de guardar uma bolsa de drogas que deixaram para ele; que todo final de semana eles abatiam um pouco da dívida; que estava trabalhando; que essa bolsa que estava com Nathalie estava guardada dentro de casa; que não sabe o que tinha dentro da bolsa, só sabe que era droga mesmo, coisa errada; que Nathalie não tinha

nenhum envolvimento; que a trouxe da casa dela um dia antes; que no dia que foi trabalhar, quando voltou, deparou-se com sua casa toda bagunçada e descobriu que a polícia tinha ido lá e tinha prendido Nathalie, a menina com quem estava ficando; que a hora que ficou sabendo disso foi à delegacia por livre e espontânea vontade, entregou-se e assumiu; que sabia que na bolsa tinha coisa de errada; que tem pessoas que não têm que pagar pelo que fez; que dentro da casa tinha a mochila que guardava, sabe que tinha droga; que a arma devia estar na bolsa, pois dentro de casa, à vista, não estava; que a bolsa foi entregue por Serafim; que só conhece Emerson de vista, lá do Mascate, onde morava, mas de ficar dialogando não; que nem sabia que Emerson estava lá; que Emerson não estava devendo, pois só conhecia de vista; que ele poderia estar pagando outra pessoa; que estava trabalhando, não o chamou para ir à sua casa; que Nathalie não saía da rua, pois não conhecia nada dali, morava em Atibaia.

O acusado Emerson Pereira dos Santos relatou que no dia ligou ao mototáxi pelo WhatsApp, para ir levar o dinheiro para o moleque, pois deve para ele o dinheiro de um boné e uma corrente; que ficou devendo, foi levar o dinheiro para ele; que mandou mensagem para ele; que o mototáxi ficou esperando; que estava chamando na casa, saiu uma mulher e falou que não era; que o policial abordou, achou R\$ 500,00 na sua blusa, levou na casa embaixo, sentou-o no chão, liberou o moleque do mototáxi; que ele falou que era para confessar; que disse que só estava com o dinheiro para Douglas, do boné e da corrente; que as drogas já estavam na viatura; que viu as drogas dentro da viatura, no banco do passageiro; que não tinha nenhuma droga; que não conhecia os policiais que o abordaram; que os policiais de Nazaré, da outra viatura, já o conheciam, o policial Romário que contou; que mandou mensagem para Douglas falando "to indo aí levar o dinheiro", mas acha que a mensagem nem chegou; que comprou esse dinheiro no carnaval do ano passado ou retrasado; que tinha perdido o contato dele por causa desses B0s; que achou o irmão dele, o Leonardo; que nunca viu Nathalie.

Verifica-se, pois, que o depoimento dos policiais é uníssono quanto à abordagem da adolescente em posse de drogas e valor em dinheiro em espécie, quando então indicou que os valores seriam de seu namorado Douglas, e indicou a residência de onde havia retirado tais objetos. Posteriormente, abordaram Emerson na mesma rua, em posse de quantidade menor de droga, mais dinheiro. Nesse rumo, vale notar que as porções de cocaína apreendidas na mochila e em poder de Emerson são de mesma espécie, acondicionadas em embalagens idênticas (cf. fotografias de fls. 29-30), o que se coaduna com a versão dos policiais no sentido de que ele estaria ali para pagar dívida e devolver drogas a Douglas.

No ponto, vale notar que as versões deduzidas em autodefesa são contraditórias entre si. Douglas relatou que não conheceria Emerson, apenas de vista. Já Emerson relatou que tinha dívida com Douglas em razão da aquisição de um boné e uma corrente no carnaval do ano passado ou retrasado. De outro lado, Emerson disse que uma mulher saiu da residência quando chamou. Já a adolescente, ouvida no processo por ato infracional (autos n. 1500277-59.2021.8.26.0695), relatou que não saiu em momento algum da casa e não viu Emerson.

Nesse cenário, ante o contraste entre as versões deduzidas em autodefesa, verifica-se que não há nenhuma razão para deixar de atribuir credibilidade ao depoimento policial colhido na espécie, no sentido de que as drogas foram apreendidas em posse de mochila carregada pela adolescente e de que, posteriormente, a arma de fogo foi localizada no interior da residência de Douglas, que posteriormente veio a reconhecer a propriedade dos bens apreendidos (drogas e arma de fogo, bem assim munições e invólucros para acondicionamento de cocaína). De igual modo, a testemunha de defesa arrolada não compareceu à audiência de instrução, de modo que não foi infirmada, quanto às circunstâncias e resultados da abordagem e busca pessoal a Emerson, a narrativa dos policiais.

Quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar que o acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas. Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito). o que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica, entre estes, o de transportar, como no caso dos autos.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

Ainda quanto à tipicidade, porém, cumpre proceder a breve reparo da capitulação do fato diante do conflito aparente de tipos penais, a fim de afastar a configuração dos crimes autônomos descritos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 em concurso com o crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06) em razão da incidência da causa especial de aumento de pena deste crime no caso de porte de arma de fogo, na forma do art. 40, IV (emprego de arma de fogo) e VI (participação de criança/adolescente), da Lei n. 11.343/06, à luz do princípio da especialidade.

Assim, também à luz do princípio da vedação ao bin in idem, impõe-se a absolvição do acusado no que toca à imputação do crime autônomo acima mencionado, ao passo que sobre a pena aplicável ao crime de tráfico de drogas deve incidir a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06 suprarreferida.

Sobre a questão, vale assentar que a leitura conjunta dos arts. 383 e 384 do CPP revela que a falta de pedido de condenação pela prática de determinado crime na peça acusatória não obsta a condenação, mas sim a falta de narrativa quanto ao fato. Tais dispositivos legais formatam o princípio da congruência (entre sentença e acusação) no direito processual penal, o qual incide em relação aos fundamentos fáticos da pretensão acusatória, mas não em relação à sua fundamentação jurídica ou em relação ao pedido (capitulação jurídica a conduta e sanções penais aplicáveis). Cuida-se de consectário da não vinculação do órgão julgador aos fundamentos

jurídicos da demanda, o qual autoriza a assim denominada *emendatio libelli* nos termos expressos do art. 383 do CPP.

Nesse cenário, no caso, deve ser reconhecida a subsunção do fato narrado na denúncia ao tipo penal constante do preceito primário do art. 33, com a incidência da majorante em tela, com a consequente absolvição da imputação do crime autônomo decorrente do mesmo fato.

Tais majorantes, porém, devem ser reconhecidas exclusivamente quanto ao acusado Douglas.

Com efeito, em relação ao acusado Emerson, embora esteja evidenciado que ele portava drogas, o acervo probatório é frágil para discernir se havia vínculo subjetivo entre os dois, de modo a se aplicar também a Emerson as majorantes em tela. A saber, está demonstrado que Douglas praticava o crime de tráfico de drogas com a colaboração da adolescente e com o emprego de arma de fogo e também está demonstrado que Emerson portava drogas destinadas ao tráfico, mas não que estivesse associado ou vinculado a Douglas, de modo a permitir que tais circunstâncias também configurem causa de aumento do crime a este imputado, à luz do art. 30 do CP, observada a vedação à responsabilidade penal objetiva.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que os acusados praticaram conduta típica e ilícita pela qual é culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n.11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

- Quanto ao acusado Douglas Junio Santos Martins

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes demonstra a existência de mais de uma condenação penal definitiva (cf. Súmula 444/STJ), a qual também configura reincidência (CP, art. 64). Assim, a fim de evitar punição dúplice pelo mesmo fato (*bis in idem*), uma delas será considerada como reincidência na segunda fase e as demais como antecedentes negativos nesta primeira fase (cf. Súmula 241/STJ e STJ, REsp 1.794.854/DF). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), passa-se ao seu exame.

Quanto à natureza da droga, verifica-se que no caso houve a apreensão de mais uma espécie de substância ilícita (maconha e cocaína), de modo a denotar maior reprovabilidade da conduta e justificar a valoração negativa de tal circunstância nesta fase da dosimetria. Sobre o tema, cf., por todos, STJ, HC 615.347/RS, DJe 15/12/2020. Quanto à quantidade de droga apreendida em poder de Douglas, houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita (quase um quilo de cocaína) suficiente para a elevação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, embora na modalidade parcial (o acusado não reconheceu a ocorrência dos fatos tais como reconhecidos nesta sentença, tentando minorar a gravidade de sua conduta), e não incidem agravantes.

Na segunda fase da dosimetria, não há limites legais mínimo e máximo de agravamento ou atenuação de pena previamente estipulados nos arts. 61 a 66 do CP. Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a aplicação da fração de 1/6 como patamar mínimo das causas de aumento/diminuição de pena constantes do Código Penal, consolidou-se a fixação da fração de 1/6 como referencial para o agravamento ou atenuação da pena em razão de cada circunstância legal, de modo que "a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). Nesse sentido, a orientação é a de que "a reincidência específica autoriza a adoção de fração maior que 1/6 na segunda fase da dosimetria" (STJ, HC 480.406/SC, Sexta Turma, DJe 25/04/2019).

Tendo em vista que a confissão foi meramente parcial no caso, aplica-se a atenuante na fração de 1/12, a resultar na pena provisória de 5 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, mais 572 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Quanto à causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a sua incidência depende do preenchimento de quatro requisitos cumulativos: (1) primariedade, (2) bons antecedentes, (3) não dedicação a atividades criminosas e (4) não integração a organização criminosa.

No caso, a folha de antecedentes comprova o preenchimento dos dois primeiros requisitos.

Por outro lado, o conjunto de objetos apreendidos demonstra a dedicação a atividades criminosas. Com efeito, o substancial montante de droga apreendida (925 papérolas de cocaína, a totalizar quase um quilo de cocaína), em conjunto com vultosa quantidade também de invólucros para acondicionamento (1000 tubos - ependorfs), bem assim a quantidade de dinheiro apreendida (R\$ 12.560,00), além das anotações de dívidas (fls. 27-28) são mais do que suficientes para demonstrar a dedicação do acusado ao tráfico de drogas em caráter habitual. Não se trata de caso que permita a aplicação da minorante, destinada ao tráfico ocasional, eventual e de pequena monta, hipótese diametralmente oposta à presente.

Incidem, por outro lado, as majorantes da arma de fogo e da participação de adolescente. Tendo em vista a incidência de duas majorantes, com reprovabilidade elevada pelo fato de a arma estar municiada quando da apreensão, a fração de aumento deve ser fixada acima do mínimo legal de 1/6, a saber, em 1/3.

Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 7 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão, mais 762 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade e as circunstâncias judiciais supra valoradas (notadamente elevada quantidade de droga apreendida, com dedicação habitual ao tráfico de drogas, ademais com a apreensão de arma de fogo e a participação de adolescente), fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado, com base no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP e observadas as Súmulas 718 e 719/STF e 269 e 440/STJ.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu em razão das circunstâncias judiciais negativas. A saber, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo, em razão da reincidência, diante do supracitado art. 33, § 2º, do CP. Sobre o tema: STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro Sexta Turma, DJe 10/12/2020; STJ, AgRg no HC 567.813/SP, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito

objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

- Quanto ao acusado Emerson Pereira dos Santos

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a folha de antecedentes juntada aos autos não contém nenhuma condenação penal definitiva apta a ser desvalorada nesta fase (cf. Súmula 444/STJ), tendo em vista que a condenação definitiva é por fato posterior ao fato-crime ora em apuração, o que não configura, pois, antecedente. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria, para fixação do patamar da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a fim de evitar bis in idem indireto, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/AM, Plenário, j. 3.4.2014, Tema 712 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1887511/SP, Terceira Seção, j. 09/06/2021).

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase, incide a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois preenchidos todos os requisitos legais já acima sumarizados. No caso de Emerson, o acervo probatório não indica sua dedicação habitual ao tráfico. Vale notar que os aparelhos celulares de ambos os acusados foram apreendidos, mas não foi requerida autorização judicial para acesso, a despeito da possibilidade reconhecida na jurisprudência (STJ, HC 51.531/R0). Assim, havia prova disponível à acusação para a demonstração de eventual vínculo entre os acusados, mas tal prova não foi produzida. Trata-se de omissão probatória juridicamente relevante que não pode importar em prejuízo ao acusado, à luz do princípio da presunção de inocência e dos princípios da melhor prova (best evidence) e da completude probatória (evidential completeness).

Quanto à quantidade da droga apreendida espescificamente com Emerson, não é exorbitante (ao revés, é diminuta). Conforme já acima apontado, não há prova de vinculação entre Douglas e Emerson a fim de que se possa imputer também a este a posse da enorme quantidade de droga apreendida com Nathalie, então namorada de Douglas. Já quanto à natureza da droga, trata-se de substância com elevado potencial nocivo à saúde e alto grau de dependência (cocaína), o que deve ser valorado negativamente nesta fase da dosimetria. Assim, fixa-se a fração de diminuição no patamar intermediário de 1/2 (um meio).

Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a primariedade do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime aberto, com base

no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP.

Não houve decretação de prisão cautelar durante o curso da persecução penal, de modo que não há detração a ser promovida neste ato (CPP, art. 387, § 2º).

Ante o preenchimento dos requisitos legais constantes do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, as quais ficam desde já individualizadas como (1) prestação pecuniária (CP, art. 45, § 1º), no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual deverá ser depositado em conta bancária que será informada posteriormente, em audiência admonitória, para destinação a entidade pública ou privada com destinação social, em atenção à Resolução n. 154/12-CNJ; e (2) prestação de serviços à comunidade, por tempo igual ao da condenação, em entidade a ser designada na fase de execução penal.

Ante a substituição por pena restritiva de direitos, fica prejudicado o exame da suspensão condicional da pena (CP, art. 77, III).

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de:

- CONDENAR o acusado DOUGLAS JUNIO SANTOS MARTINS ao cumprimento de 7 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 762 dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33 e 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 65, III, "d" do CP.

- CONDENAR o acusado EMERSON PEREIRA DOS SANTOS ao cumprimento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos na forma supra, mais 250 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto à manutenção da prisão cautelar de Douglas, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação no acórdão do Tribunal de Justiça permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do acusado. Recomende-se ré o réu na prisão em que se encontra.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único). Quanto à arma de fogo e às munições apreendidas, deve ser decretada a perda em favor da União. Encaminhem-se ao Comando do Exército para destruição, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custas pelos réus, pro rata (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade, em relação

ao acusado Emerson, em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).
Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.
Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.
Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Nazaré Paulista, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA